

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

15309/2553

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายชาญชัย บุญฤทธิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง, มาตรา 277 วรรคสาม, มาตรา 279 วรรคแรก

การที่จำเลยเพื่อสนองความใคร่ของตนเองให้ผู้เสียหายที่ 1 อายุยังไม่เกิน 13 ปี อมอวัยวะเพศของจำเลยเป็นการใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 1 เป็นการกระทำชำเราตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี และการที่จำเลยให้ผู้เสียหายที่ 3 เลียอวัยวะเพศของจำเลยโดยที่อวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในปากของผู้เสียหายที่ 3 จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 เพราะช่องปากเป็นที่ว่างในปาก ซึ่งมีปากเป็นทางเข้าออก โดยต้องผ่านปากเข้าไปก่อนจึงจะถึงช่องปาก เมื่ออวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในปากของผู้เสียหายที่ 3 ย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นการกระทำชำเราตามความหมายของกฎหมายดังกล่าว การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จำเลยขอถอนคำให้การเดิมและ ให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม, 317 วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาหรือสามีของตน จำคุกกระทงละ 7 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 14 ปี รวมเป็นจำคุก 34 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 17 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ก่อนรวมโทษ เมื่อลดโทษให้จำเลยเป็นรายกระทง กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 8 ปี 24 เดือน และจำคุกฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 6 ปี 12 เดือน รวมจำคุกทั้งสิ้น 14 ปี 36 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาประการแรกว่า การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 1 เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี หรือไม่ ปัญหานี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง บัญญัติความหมายของการกระทำชำเราไว้ว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำ กับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น การที่จำเลยเพื่อสนองความใคร่ของตนเอง โดยให้ผู้เสียหายที่ 1 อมอวัยวะเพศของจำเลยเป็นการใช้อวัยวะเพศของจำเลย กระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 1 เป็นการกระทำชำเราตามความหมายของ กฎหมายดังกล่าว การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 1 เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี

และปัญหาประการที่สองว่า การที่ผู้เสียหายที่ 3 เลียอวัยวะเพศของจำเลย โดยที่อวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในปากของผู้เสียหายที่ 3 เป็นกรณีที่จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 หรือไม่ เห็นว่า ช่องปาก เป็นที่ว่างในปาก ซึ่งมีปากเป็นทางเข้าออก โดยต้องผ่านปากเข้าไปก่อนจึงจะถึงช่องปาก เมื่ออวัยวะเพศของจำเลยไม่ได้เข้าไปในปากของผู้เสียหายที่ 3 ย่อมถือไม่ได้ว่า จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นการกระทำชำเราตามความหมายของกฎหมายดังกล่าว การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับการกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 3 ตามฟ้องข้อ ง. ไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279

วรรคแรก ลงโทษจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกกระทงอื่นตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ภาค 7 แล้ว เป็นจำคุกจำเลย 11 ปี 33 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(ประทับ ดุลพินิจธรรมา-สนอง เล่าศรีวรกต-สุริยง ลัมสถิรานันท์)

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - นายวีระพล เทียนขก

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายเกรียงศักดิ์ คงผล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ331/2552

ต้น

หมายเหตุ